

1019570-29.2019.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação

Magistrado: Lais Helena Bresser Lang

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 2ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... praticou ato infracional assemelhado ao crime de tráfico de substâncias entorpecentes ilícitas - drogas, quando possuía 17 (dezesete) anos de idade. Autor que não possui registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado. Candidato que não pode ser apenado por eventuais condutas criminosas perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio. Ausentes indícios de sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

2ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo nº:

1019570-29.2019.8.26.0053 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Luiz Henrique Silva de Oliveira

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lais Helena Bresser Lang

Vistos.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Luiz Henrique Silva de Oliveira contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando anulação de ato administrativo que o desclassificou de concurso público. Narra, em síntese, que se inscreveu regularmente no concurso público para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe, conforme Edital de Abertura DP-1/321/18. Todavia, foi reprovado na investigação social. Requereu a concessão de tutela provisória, a fim de reservar sua vaga no certame. E, ao final, a anulação do ato administrativo que o reprovou; além da condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Juntou documentos e à causa deu-se o valor de R\$ 99.800,00.

A gratuidade da justiça foi deferida. No entanto, a liminar restou indeferida.

A Fazenda apresentou contestação às fls. 88/100. Sentença julgou improcedente o pedido inicial, fls. 241/243. Em sede de Apelação foi dado provimento ao recurso do autor, voltando os autos à origem, para que seja dado seguimento ao processo com abertura do prazo para réplica.

Houve réplica, fls. 336/342.

Relatados. Fundamento e decido.

A ação comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de dilação probatória.

De início, consigna-se que, dentro de sua margem de discricionariedade, a Administração deve obedecer aos princípios impostos pela Constituição Federal e, dentre eles, o primeiro a ser observado é o da legalidade. Em não havendo a devida observância, é autorizado ao Poder Judiciário pronunciar-se, ficando garantido o direito de qualquer pessoa de se socorrer do Poder Judiciário quando da ocorrência de violação a direito. Assim, mesmo se tratando de ato eivado de poder discricionário, cabe ao Judiciário fazer o controle da legalidade dos atos da administração. E, não sendo adequada a motivação, resta reconhecer a nulidade do ato, como ocorre no caso em análise.

Alega a ré, em síntese, que o autor não atende aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada, reputação ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por um comportamento social irrepreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício do cargo de militar de Estado, pois identificadas as condutas listadas no item 5 do capítulo XII do Edital, as quais impedem a aprovação do inscrito:

itens 5.2: Toxicômano ou drogadicto;

5.13: Pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes;

5.29: Possuidor de comportamento desabonador nas Forças Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares;

5.18: Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Não é nova a discussão acerca da desclassificação de inscritos em concursos para provimento de cargos da Polícia Militar. E, em processos análogos, entendo que a Administração não pode apenas se valer do que contido no Edital, mas cotejar suas disposições com uma análise pessoal de cada candidato. Poderia se cogitar que a análise da Administração é rígida, mas assim a deve ser, vez que se trata de um poder/dever da Administração Pública eleger apenas candidatos possuidores de histórico de conduta e perfil ético social e moral, compatíveis para o cargo almejado, plausível e adequado.

Por outro lado, alega o autor, no exercício do contraditório e da ampla defesa, que os fatos trazidos pela requerida não têm qualquer respaldo documental hábil a comprovar a legalidade de sua desclassificação no certame.

Decerto, quando o candidato omite ou distorce as informações que deveriam ser exaradas no Formulário de Investigação Social, demonstra que, além de assumir a inexatidão dos dados apresentados, age supostamente de forma dolosa, por tentar, com essa conduta, eventual omissão na Etapa da Avaliação e ludibriar a Administração do concurso. E constou, não só no edital do concurso, mas também na contracapa do próprio Formulário, entregue a todos os candidatos, as consequências das inexatidões, omissões e falseamentos de informações em seu preenchimento, ou seja, o Edital é claro quanto à consequência de declarações falsas ou omissões, qual seja, o impedimento da aprovação. Tal atitude, como de se esperar, dificulta a boa coleta de dados e informações. No entanto, ao contrário do alegado pela requerida, o autor não faltou com a verdade ao afirmar que não havia tido nenhuma punição administrativa disciplinar quando serviu as Forças Armadas Brasileiras; conforme se verifica quando do preenchimento do formulário, fls. 173. Punição que não foi grave, tratando-se apenas de uma punição por ter chegado atrasado a uma consulta médica. Não se trata, portanto, de infração grave que teria o condão de demonstrar que o autor desconhece disciplina e hierarquia, ou que não seguia as ordens impostas por seus superiores.

Não apenas isso. Aduz a requerida que a pesquisa social identificou que o candidato serviu no período de 28FEV14 a 31JAN16 junto a Academia da Força Aérea Brasileira - FAB, localizada na cidade de Pirassununga/SP, como Soldado, e durante este período teria se a informação de envolvimento habitual e indiscriminado com substâncias

entorpecentes ilícitas – drogas. Inclusive diz ter constatado que o autor e um amigo comentavam frequentemente sobre o uso de drogas. Além de ser averiguado que possuem um amigo que é traficante de drogas ilícitas.

No tocante à manutenção de amizade ou convivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes, entende-se a sensibilidade e a precaução da requerida pois, como bem salienta na contestação, em trecho que ora transcrevo, in verbis: Em razão do importante papel social que desempenha perante a sociedade paulista, seus integrantes devem ser selecionados sob a mais absoluta retidão de conduta social, reputação e idoneidade moral, pois deste tipo de profissional (militar de Estado), espera-se e almeja-se que sejam agentes públicos fiéis e cumpridores das leis e das normas estabelecidas, honrando os mais altos valores sociais de justiça e convívio, não sendo admissível conduta diversa, pois os pressupostos exigidos para ser um guardião da sociedade devem ser analisados e considerados de forma abrangente e não somente mensurar se o pretendente é criminoso ou não.

Todavia, ainda que o autor mantivesse relação de amizade com supostos infratores, o que, repito, não foi comprovado, não pode o autor sofrer as consequências da transgressão cometida por seu amigo. Permitir isso seria ir na contramão de direção ao princípio da individualização da pena, posto que ele também sofreria uma sanção, acarretada pela suposta má conduta de seu amigo. As alegações que traz a ré, nesse contexto, não comprovam a conduta desabonadora na vida pregressa do candidato. Isto porque o Direito Administrativo é regulado pelo princípio da presunção da legitimidade dos atos administrativos. Essa presunção é, contudo, relativa. Caso o ato administrativo seja contestado em juízo, cabe à Administração Pública demonstrar a legalidade dos atos. No caso, caberia à recorrida comprovar que o autor é usuário de drogas e ou possui amigos que são usuários e ou traficantes. O que não o fez. Não há qualquer documento hábil a comprovar essa alegação, inclusive o autor realizou exame toxicológico, o qual foi aprovado. Caindo por terra a alegação de que seria ele usuário de entorpecentes.

Ademais, se o uso de drogas vinha ocorrendo durante o período que serviu nas Forças Armadas, como pode o autor ter feito jus ao certificado de Mérito, como se depreende de fls. 348, que atestam prova de distinção excelente atividade e modelar comportamento; além de ter sido expedida declaração exarada pelo comando da Aeronáutica Academia da Força Aérea que atesta que o autor, ex-soldado da Academia, não respondeu qualquer processo judicial perante a Justiça Militar, tem comportamento classificado como BOM e que não sofreu punição grave, fls. 356 e 347.

Na verdade, a investigação social não logrou apurar qualquer fato ou circunstância capaz de desabonar a pessoa do autor, que não pode então ser penalizado pelo suposto mau comportamento de seu amigo.

Como bem disserta o Nobre Desembargador Aroldo Viotti, no voto em caso análogo, qual seja, a Apelação nº 1033105-59.2018.8.26.0053, que ora transcrevo:

“O edital do concurso não contém dispositivo que ampare esse “discrimen”, e se o contivesse, seria ele claramente atentatório à Constituição Federal, que, dentre outros princípios, consagra o da personalização das penas, o de que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado” (CF, art. 5º, inc. XLV).

Como anota JOSÉ AFONSO DA SILVA: “... a personalização da pena acaba sendo um princípio de justiça retributiva: premiar ou castigar segundo o merecimento do agente, só do agente, na mesma proporção do benefício ou do dano causado. Injusto fora e mais seria no Estado Democrático de Direito apenar alguém por fato de outrem” (“Comentário Contextual à Constituição”, Malheiros Ed., 2005, pág. 143).

E assim é a Jurisprudência, em casos análogos:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2ª CLASSE. Candidato considerado inapto, em fase de investigação social, sob o fundamento de convivência com irmão que praticou ato infracional assemelhado ao crime de tráfico de substâncias entorpecentes ilícitas - drogas, quando possuía 17 (dezessete) anos de idade. Autor que não possui registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado. Candidato que não pode ser apenado por eventuais condutas criminosas perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio. Ausentes indícios de sua participação ou colaboração. Inexistência de outros elementos desabonadores. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Honorários advocatícios. Valor da causa que teve como base o pedido de indenização por dano moral julgado improcedente. Valor inestimável do pedido acolhido. Verba honorária reduzida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Relator: Desembargador Avez Braga Junior - Apelação n. 1054239-45.2018.8.26.0053 Órgão Julgador 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Data de Julgamento: 10/3/20)

APELAÇÃO Concurso Público para Soldado da Polícia Militar. Candidato excluído do certame por ter sido reprovado em investigação social, em razão de manter relação de amizade/convívio com pessoas envolvidas com o consumo de tóxicos (parentes e um amigo), bem assim porque teria omitido dados no respectivo formulário. Pretensão à reintegração no certame e à indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Acolhimento parcial. Autor contra quem pessoalmente nada se apurou nessa fase. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente a ação, determinando a reintegração do autor ao certame. Desacolhido o pedido de indenização por danos morais. (Relator Desembargador Aroldo Viotti - Apelação nº 1033105-59.2018.8.26.0053 Órgão Julgador 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Data de Julgamento: 19/2/2019)

No tocante ao dano moral, inexistente. É pacífico na doutrina o entendimento de que, para a configuração do dano moral e, conseqüentemente, de sua respectiva indenização, um simples aborrecimento não é suficiente.

Da lição de Sergio Cavalieri Filho, " (...) só deve ser reputado com dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar."

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimento.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e extinto o processo, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para anular o ato administrativo que reprovou o autor, na etapa do concurso objetivado, referente à investigação social, a fim de que prossiga nas demais fases do certame, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, valendo a presente como ofício. Ante a sucumbência, arcará a parte requerida com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Deixo, contudo, de utilizar o valor da causa, como base de cálculo, pois sua estimativa teve lastro, na pretensão por danos morais, o que foi rechaçado pelo juízo. Sendo assim, fixo os honorários em R\$ 3.000,00 (CPC, art. 85, parágrafo 8º). Os honorários serão corrigidos pela Tabela Prática do TJSP para débitos judiciais, pois esta é a natureza desta verba. Dispensável o reexame

necessário.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as devidas anotações.
P.R.I.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA

DATA

Recebi em cartório em ____/____/2020
Eu, _____ escrevente, subscrevi.